

1502542-29.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502542-29.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502542-29.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268021/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 20588748 - 01º D.P. GUARULHOS, 3290/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LELSON BARBOSA DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LELSON BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 20h50min, na Rua Tenente Campo, nº 293, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 5,6g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 4 invólucros, e 31,3g de cocaína distribuídos em 85 invólucros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência a fls. 7/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 17/19) (fls. 48/49).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/44).

Devidamente notificado (fls. 61/62), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol

de testemunhas comuns (fls. 69/70).

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022 (fls. 71/75).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 13/15), laudo de constatação provisória (fls. 17/19), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/128), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL-THC, laudo pericial de objeto (fls. 123/125), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado LELSON BARBOSA DE SOUZA, em solo policial, fez uso do direito constitucional de ficar em silêncio (fl. 06). Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que trabalhava fazendo malabares no farol. No dia, ganhou um pouco de dinheiro no farol e foi até a biqueira comprar drogas. Depois de comprar o entorpecente foi abordado. Estava apenas com quatro pinos de cocaína para seu uso. A sacola com as drogas foi encontrada em um muro. Acredita que os policiais o acusaram injustamente porque não gostam que ele é usuário e fica no farol. Não conhecia Guilherme e não soube dizer porque ele teria dito que comprou drogas com ele. Já foi processado por tráfico quando era menor e também tem uma condenação por tráfico já quando era maior.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

O policial militar FÁBIO ALMEIDA MACEDO, em solo policial, narrou que, na data dos fatos, por volta das 20h50min, foi acionado pelo COPOM para atender ocorrência de venda de entorpecentes, onde o traficante vestia blusa verde escura e boné vermelho. Quando chegou na viela Tenente Campo, avistou Lelson e Guilherme próximos. Ambos correram quando viram a vtr, mas foram detidos. Junto com a SDPM Mecheto conseguiu deter Guilherme, enquanto o SGT PM Cruz, que estava no apoio, conseguiu deter Lelson. Fez revista em Guilherme e com ele localizou 1 pino de pó amarelado parecendo ser crack escondido dentro da boca. Posteriormente, fez revista pessoal em Lelson, com quem achou, no bolso da bermuda, a quantia de R\$ 126,75, 4 porções de pó branco parecendo ser cocaína e 1 cachimbo. Enquanto fugia, ele dispensou uma sacola plástica que foi recuperada. Dentro dela havia 85 pinos no total, pois eles estavam misturados dentre crack e cocaína. Conversou com Guilherme, que disse que foi até o local para comprar a droga, pois ele é usuário. Ele também apontou o indiciado como sendo o traficante que vendeu o pino para ele. Diz que não conseguiu conversar com Lelson porque ele fingiu um desmaio, tanto que foi acionado o SAMU para ele. Depois de receber atendimento médico e ser liberado, tudo pelo local, a ocorrência foi trazida para o DP (fl. 02). Em juízo, relatou que no dia recebeu denúncia pelo COPOM, de indivíduo na prática de tráfico de drogas na rua Tenente Campos. A denúncia passou as características do indivíduo. Pelo que se recordava, o rapaz estaria usando boné vermelho, camiseta e shorts, não se recordando de mais detalhes. Explicou que o local é uma comunidade, sendo que fizeram um cerco, assim enquanto uma viatura desceu pela Rua Tenente Campos, ele, sua parceira e o Sargento acessaram o local por uma viela. Na viela abordaram dois indivíduos. Sua parceira ficou com esses dois, enquanto ele e o Sargento continuaram descendo a viela. Explicou que o réu apareceu correndo em sua direção, quase trombou com ele e o Sargento, e tentou dispensar uma sacola. Abordado o réu fingiu ter desmaiado. O samu foi chamado e o réu acabou despertando. Com o réu

apreenderam dinheiro e algumas porções de drogas. A sacola que o réu estava também foi apreendida e havia mais porções de entorpecente. Com os indivíduos inicialmente abordados, um não tinha andas e o outro estava com uma porção de droga na boca. Esse rapaz falou que comprou a droga com Lelson. Disse que o local é um ponto de tráfico conhecido. Já havia visto Lelson, no farol, mas nunca o abordou.

A policial militar GÉSSICA RITA BATISTA DE SOUZA MECHETO, em sede policial, narra que, na data dos fatos, por volta das 20h50min, foi acionada pelo COPOM para atender ocorrência de venda de entorpecente, onde o COPOM ainda informou que havia um rapaz negro, usando boné vermelho, fazendo a venda de entorpecente pela Viela Tenente Campo, altura do numeral 293, para onde imediatamente se deslocou. Chegando no local, deparou-se com a pessoa posteriormente identificada como Lelson Barbosa de Souza trajando boné vermelho. Ele, que é negro, ou seja, detentor de características físicas e vestimentas iguais àquelas narradas pelo COPOM, tentou fugir, mas passou mal e desmaiou, sendo detido por seu colega de farda, SDPM Macedo. Com ele, no bolso da bermuda que travava, havia a quantia de R\$ 126,75 em espécie, um cachimbo e 4 pinos contendo pó branco parecendo ser cocaína. Ele trazia nas mãos uma sacola plástica contendo 85 pinos, alguns contendo pó branco que parecia ser cocaína e outros contendo pó amarelado que parecia ser crack, bem como 4 porções de erva verde parecendo ser maconha. Esclarece que, quando chegaram, próximo de Lelson estava a pessoa depois identificada como Guilherme Ferreira dos Santos. Ele não tentou fugir. Em revista pessoal feita nele, foi achado dentro da boca apenas um pino contendo pó amarelo parecendo ser crack. Ele não portava dinheiro. Indagado, Lelson, que pareceu ter fingido um desmaio e foi socorrido no próprio local pela vtr SAMU de prefixo DT2328, Enc Alex, nada quis falar. Já Guilherme, quando inquirido, disse ser usuário e que só foi até lá para comprar droga, afirmando que foi Lelson quem vendeu a cocaína para ele. Diante dos fatos, trouxeram ambos para a DP, junto com o dinheiro e as substâncias. Consigna que apenas Lelson foi algemado. Toda a abordagem policial foi gravada pela body cam (fl. 03). Em juízo, relatou que no dia dos fatos, o COPOM noticiou ocorrência de tráfico no local, passando as características dos indivíduos que estariam realizando o tráfico, a s quais não se recorda mais. No local, abordaram dois indivíduos, sendo que com um deles nada foi encontrado, então, seus dados foram anotados e ele foi dispensado. O Com o segundo rapaz encontraram um porção de droga escondida na boca, ele disse que era usuário e foi levado ao D.P. Quando estavam abordando esses dois, o réu apareceu próximo de onde estava. Ele tentou correr, mas seu parceiro e o policial Cruz conseguiram detê-lo. Seu parceiro disse que o réu teria dispensado uma sacola, mas não chegou a ver, porque estava com os dois que tinham sido abordados antes. Informou que o réu quando viu que ia ser abordado fez que desmaiou. O SAMU foi chamado e feito teste de dor, o réu acordou. Ao ser revistado, com o réu foi encontrado dinheiro e algumas porções de cocaína. Na sacola que seu parceiro viu o réu dispensar foram encontradas mais drogas. Não se recordou se o réu chegou a confessar o tráfico. Disse que o réu apresentava as características informadas na denúncia. Esclareceu, ainda, que o indivíduo que foi encontrado com uma porção de droga disse que teria comprado o entorpecente do acusado. Não conhecia os indivíduos.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Por fim, a testemunha GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS, ouvida apenas em solo policial, alegou que foi "pegar" droga na "biqueira" perto do 9DP. Diz que foi pegar "pedra", pois é usuário faz 3 anos. Também é usuário de maconha e pó. Ocorre que depois de comprar uma única pedra pela quantia de R\$5,00 de "Neguinho" (referindo-se ao indiciado, preso no DP) levou um "enquadro". Diz que conhece "Neguinho" de vista, pois já comprou droga dele outras vezes e também pelo fato de morar atrás da viela onde os fatos aconteceram. Na hora do quadro tentou esconder seu único pino, comprado para consumo próprio, na boca, mas os policiais acharam e disseram que iriam lhe trazer para o DP. Viu quando "Neguinho" tentou correr fugindo, mas os policiais conseguiram pegar ele quando ele desmaiou. Ele tinha uma sacola cheia de drogas na mão. Não estava portando nenhum cachimbo, mas ouviu os policiais falarem que tinham achado um cachimbo com "Neguinho" (fl. 04).

Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares, ouvidos na fase policial e em juízo, além da localização dos entorpecentes em poder do acusado, acrescido do depoimento extrajudicial da testemunha Guilherme, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que LELSON trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Ademais, embora não tenha sido ouvido em juízo, a confirmar o depoimento dos policiais há ainda nos autos o depoimento extrajudicial da testemunha Guilherme, o qual confirmou que o réu estaria traficando no local, não havendo também razão para este juízo acreditar que Guilherme teria falsamente acusado o réu.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (5,6g de Tetrahidrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 4 invólucros, e 31,3g de cocaína distribuídos em 85 invólucros), da forma como estavam embaladas, em pequenas porções prontas para a comercialização, das circunstâncias em que se deu a prisão do denunciado, em constatação de notícia anônima, além da apreensão de certa quantia em dinheiro em poder do réu, cujo origem lícita não conseguiu provar.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos

variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

O fato do réu ser usuário de drogas como alega não afasta sua responsabilidade criminal, até porque é comum usuários se envolverem com a prática do tráfico de drogas para garantir recursos financeiros para com parar o entorpecente. O réu, inclusive, não é a primeira vez que se envolve com a traficância, seja quando menor ou já maior de idade.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, verifico que o réu praticou o delito nas condições normais previstas no tipo penal (sua condenação anterior será levada em conta na segunda fase de aplicação da pena), podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que a quantidade de entorpecente apreendido não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base (5,6g de Tetrahydrocannabinol-

THC, conhecida como maconha, distribuídos em 4 invólucros, e 31,3g de cocaína distribuídos em 85 invólucros).

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 1520170-16.2020.8.26.0228, da 32ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda - processo de execução da pena nº 0014558-52.2021.8.26.0224, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 117/118 e FA de fls. 106/110 e fls. 111/115), sendo, portanto, reincidente específico. Assim, acresço as penas de 1/6 (um sexto), fixando as penas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas, razão pela qual torno, em definitivo, a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que, em face da reincidência, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise. Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”. (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostraram adequados para a ressocialização do réu, além do fato do réu ser reincidente específico, evidenciando que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o fato do acusado ser reincidente específico, além permanecido preso durante todo o processo, não poderá o réu recorrer liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrin Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com

reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR LELSON BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Considerando-se a relação do dinheiro apreendido (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12) com o tráfico ilícito de entorpecente, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Antidrogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 05 de abril de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA